

在假释考验期限内发现漏罪的并罚方式进行了规定，但是对“发现”的界定存在以下两种处理意见：

第一种处理意见，严格从法条本意理解，“发现”的时间节点应为狭义的假释考验期限内，若侦查机关在假释考验期限以前发现漏罪的，不属于《中华人民共和国刑法》第八十六条第二款规定的情形，此时，漏罪的审理法院无需撤销假释，应当直接依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定实行数罪并罚。

第二种处理意见，“发现”的时间应为广义的假释考验期内，在假释考验期开始以前发现的漏罪，因办案流程等原因未能在被假释以前将罪犯押解办理漏罪的，罪犯在被裁定假释后，该漏罪的“发现”状态一直持续，仍可以理解为在假释考验期限内发现漏罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第八十六条第二款的规定，在漏罪判决中先撤销假释，再依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定实行数罪并罚。

对于《中华人民共和国刑法》第八十六条第二款中“发现”的界定，司法实践中较为认同第二种处理意见。本案中，某市公安局于2022年2月（前罪服刑期间）经侦查发现被告人侍某某为本案犯罪嫌疑人，于2022年11月8日（假释考验期间内）将被告人侍某某抓获并对其刑事拘留。因公安机关为避免超期侦查，在发现被告人侍某某的漏罪情况时，未对其采取强制措施或从服刑机关解回，导致最终采取强制措施的时间点卡在被告人侍某某的假释考验期限内。若仅按照第一种处理意见，对侍某某的漏罪进行数罪并罚，人民法院作出的假释裁定具有法律效力但因罪犯被数罪并罚而无法执行，罪犯仅能被收

监执行漏罪判决后决定执行的刑罚，此种处理方案必然会导致被告人的刑罚与执行的变更程序并不严密；若按第二种处理意见，某市公安局在2022年2月侦查发现侍某某为本案犯罪嫌疑人，这种发现状态必然延续至2022年11月侍某某在假释考验期限内被刑事拘留之时，故侍某某属于在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前（在假释考验期限内）被发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销假释，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行

数罪并罚，此种处理方案既给前罪的假释裁定画上一个句号，又将被告人的漏罪依法进行数罪并罚。此种处理方式，使得后罪判决对罪犯在全案中刑罚执行的逻辑上更为严密。

此外，在依据《中华人民共和国刑法》第六十九条对被告人进行数罪并罚时，审理法院应当充分注意到被告人在前罪服刑期间被假释的情况，综合考虑被告人认罪悔罪态度、再犯罪的危险等，在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情适当就低决定执行的刑期，以更有利于保障被告人的权益，以确保罪责刑相适应。

编写人：江苏省江阴市人民法院 陈梦 陈民洲 方燕燕

（四）缓刑

49

撤销缓刑案件的审查标准

—— 苏某某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市荔湾区人民法院(2022)粤0103刑更4号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2020年12月17日，广东省广州市荔湾区人民法院作出刑事判决书，以诈骗罪判处罪犯苏某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000

元。原判已发生法律效力并交付执行。

广东省广州市越秀区司法局认为罪犯苏某某在接受社区矫正期间违反社区矫正监督管理规定，符合撤销缓刑条件，向广东省广州市荔湾区人民法院提出申请撤销缓刑建议。

罪犯苏某某对撤销缓刑建议有异议，认为其不是故意拆卸电子手环，不当撤销缓刑。

法院经审理查明：2021年9月18日罪犯苏某某因在2021年8月至9月多次未能按规定通过“穗智矫”小程序报告个人位置信息，经两次训诫未改正且未按规定参加2021年9月10日的教育学习活动，经教育未改正，被社区矫正机构给予第一次警告；2022年3月2日，社区矫正机构针对罪犯苏某某使用电子定位装置期间存在脱卸电子手环的情形，给予第二次警告；受到社区矫正机构两次警告后，罪犯苏某某又在2022年3月15日拆卸电子手环。另查明，罪犯苏某某于2022年2月25日晚上拆卸电子手环放在家里充电，次日下午到社区矫正机构参加公益活动时被工作人员发现没有按规定佩戴电子手环；2022年3月16日，社区矫正机构工作人员发现罪犯苏某某有拆卸电子手环行为，要求其到司法所报告电子手环使用情况，罪犯苏某某称，其于2022年3月15日晚上因电子手环太紧找一钟表店调松手环一格。前述缓刑考验期内，罪犯苏某某没有离开广州市。

【案件焦点】

社区矫正机构对缓刑犯作出的“警告”，人民法院能否进行实质审查。

【法院裁判要旨】

广东省广州市荔湾区人民法院经审理认为：执行机关广州市越秀区司法局在罪犯苏某某接受社区矫正期间，作出第一次警告后，于2022年2月25日至2022年2月26日拆卸电子手环，依据《中华人民共和国社区矫正法实施办法》第三十五条第六项的规定，作出第二次警告，但第二次警告适用依据“其他违反监督管理规定”缺乏具体援引，属于适用依据不明确，且罪犯苏某某该次行

为与《中华人民共和国社区矫正法实施办法》第三十五条项下“其他违反监督管理规定，情节较重的。”不具有相当性，对广州市越秀区司法局第二次作出的警告，不予支持。因此，罪犯苏某某行为不符合《中华人民共和国社区矫正法实施办法》第四十六条第一款第四项规定情形。依照《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，裁定如下：

不予撤销本院(2020)粤0103刑初1162号刑事判决中对罪犯苏某某的宣告缓刑二年的执行部分。

【法官后语】

本案争议的焦点是社区矫正机构对缓刑犯作出的“警告”，人民法院能否进行实质审查。

1. 人民法院应当对社区矫正机构提出的撤销缓刑建议书从合法性、合理性角度进行实质审查，审查社区矫正机构作出的警告能否成立。

缓刑犯社区矫正是非监禁刑罚执行制度。本案中，苏某某符合“受到执行机关二次警告，仍不改正的”形式要件，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第五百四十三条第一款第四项规定，人民法院收到社区矫正机构的撤销缓刑建议书后，经审查，确认罪犯在缓刑考验期限内具有“受到执行机关二次警告，仍不改正的”情形，应当作出撤销缓刑裁定；但是，若人民法院对社区矫正机构提出的申请撤销缓刑建议只是进行形式审查，显然不符合缓刑犯社区矫正作为刑罚执行性质，亦杜绝了缓刑犯救济方式，违背了有权利必有救济的法理。从合法性层面来看，苏某某受到第二次警告的文书，社区矫正机构不仅没有明确载明其违反监督管理规定的具体条文，也没有在电子设备告知书上载明

违反后的法律后果、救济途径，以及依据“其他违反监督管理规定”亦缺乏援引具体条文，因此，社区矫正机构作出“警告”程序不当、依据不明。从合理性层面来看，苏某某2022年2月25日晚上拆卸电子手环放在家里充电属于常识、常理、常情，如戴着电子手环充电既不方便也不安全，且苏某某次日下午到社区矫正机构参加公益活动，也没有证据证明苏某某在缓刑考验期内离开广州，这说明不仅没有逃避公益活动的行为，

